【例 1-1】分析

本案张某作为乙门市部的采购员，虽然具有代理资格，但其作为代理人，与第三人恶意串通，损害被代理人的利益，应由代理人与第三人承担连带责任。因此，本案张某应该与甲厂对乙门市部承担连带赔偿责任。由于《民法典》规定的普通民事诉讼时效为三年，本案并没有过时效，乙门市部可以要求甲厂和张某承担赔偿责任。

【例 1-2】分析

《民法典》第一百六十九条第二、三款规定，转委托代理未经被代理人同意或者追认的，代理人应当对转委托的第三人的行为承担责任。但是，在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代理的除外。可见，本案代理人由于情况紧急，为了维护被代理人利益进行转委托，符合上述规定的“紧急情况”，即使未经被代理人同意或追认，也应该认为是有效的，损失应该由甲承担。第二个问题是假设丙喝醉了酒，忘了关车门，导致汽车和服装全部被偷走，从而导致责任的承担问题。通过对第一个问题的分析可知，在转委托有效成立的情况下，丙作为代理人，就应该遵守代理人的职责，根据《民法典》第一百六十四条的规定，代理人不履行或者不完全履行职责，造成被代理人损害的，应当承担民事责任。可见，汽车和服装的损失都应该由丙承担。

【例 1-4】分析

房屋买卖必须经过登记才能发生所有权移转，但当事人之间的房屋买卖合同，只要依法达成合意就已经生效了，就应当在当事人之间产生拘束力。没有办理登记不发生物权移转的效力，但 A、B 之间的商品房买卖合同应当合法有效。因此，如果一方存在违约行为，并不影响另一方根据合同要求其承担违约责任。本案中买方可以依据合同，追究卖方的违约责任。最高人民法院 2012 年 7 月 1 日起施行的《关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》对此类问题也作了明确规定，根据该司法解释第三条第二款的规定，出卖人因未取得所有权或者处分权致使标的物所有权不能转移，买受人要求出卖人承担违约责任或者要求解除合同并主张损害赔偿的，人民法院应予支持。

【例 1-5】分析

A 将 B 的房屋以自己的名义进行了产权登记并转让给 C，C 支付了对价并办理了产权登记，即使事后证明 A 当初的产权登记是不对的，但因为丙是相信了产权登记而购买的房屋，根据公信原则，其权利应当受到法律保护，甲与丙之间的交易应当有效。因此，公信原则实际上是赋予了公示的内容公信力。

【例 1-6】分析

该案是全国首例空调热风侵权判例，也使相邻权原理在法院的判决中得到很好的体现。

【例 1-7】分析

本题涉及按份共有人的权利和责任问题。

1.本问涉及优先购买权的行使问题。乙、丙均为共有人，其优先购买权是平等的，故应尊重出卖份额所有人的意志，因此，由甲决定将该份额转让给乙或丙。

2.本问涉及抛弃份额的归属问题。抛弃份额归其他共有人，但其他共有人对其份额如何分配，依据所有权的弹力性原则，其他共有人按照自己的份额相应增加。

3.本问涉及责任承担问题，花盆掉落无疑是甲的过错造成的，甲因此应负过错责任。

4. 本问涉及共有物致人损害的赔偿问题。修缮房屋是全体共有人的义务，因此，共有物致人损害属不可分之债，共有人负连带责任。

【例 1-9】分析

本题涉及抛弃物的所有权归属问题。权利人可抛弃自己享有所有权的物品，对于抛弃物，可依相应法律规定或习惯，由拾得人基于先占而取得所有权。本题中，王某抛弃其病牛，刘某牵回家中，刘某即取得对该牛的所有权，故第三种意见是正确的。

【例 1-11】分析

根据《民法典》第六百零四条的规定，买卖合同标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。本案中买卖双方约定第二天交付标的物驴子，但在交付之前标的物毁损（被雷电电死），在不存在法律另有规定或当事人另有约定的情况下，本案的风险应该由出卖人承担。

【例 1-12】分析

1.当事人的诉权不会因为诉讼时效届满而消失，所以本案当事人依然享有诉权；

2. 被告若不以时效届满提出抗辩，法院不可以主动以时效届满驳回起诉。《民法典》第一百九十三条规定，人民法院不得主动适用诉讼时效的规定。

3. 《民法典》第一百九十二条第二款规定，诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩；义务人已自愿履行的，不得请求返还，因此，偿还了借款之后才发现诉讼时效已过，再起诉要求予以返还的，法院不予支持。

【例 2-1】分析

悬赏广告是不同于一般广告的一种特殊广告形式。它是广告人以广告的形式声明对完成悬赏广告中规定的行为的任何人，给予广告中约定的报酬的意思表示行为。对于悬赏广告的性质，我国理论和司法实践多数意见都把悬赏广告作为要约看待。《民法典》第三百一十七条第二款规定，权利人悬赏寻找遗失物的，领取遗失物时应当按照承诺履行义务。《民法典》第四百九十九条规定，悬赏人以公开方式声明对完成特定行为的人支付报酬的，完成该行为的人可以请求其支付。

有兴趣的读者可搜索一些相关判例，比如，北京市朝阳区人民法院的判决：作家张一一（本名张义）在其某新书出版时在微博公开发布悬赏广告，承诺挑出一个错奖赏 1001 元；山西大学文学院教授白平认为该书存在 172 处错误，将张义诉至法院索要悬赏奖金 17 万余元，最终获得法院认定书中存在 18 处知识性错误，判令张义向白平支付报酬 18018 元。

【例 2-2】分析

本案受要约人在要约还没有生效（到达生效）时即作了所谓的“承诺”，这个“承诺”不能视为有效承诺，只能看作是一个要约，这种情况在外贸上属于“cross-offer”，即“交互报价”，不视为合同有效成立。

【例 2-3】分析

本案主要考核对要约撤回和要约撤销两个概念的辨析。注意，要约撤回与要约撤销是两码事，只要符合要约撤回的法定要件，即使是不可撤销要约，也是可以被撤回的。

虽然本案中要约人在要约中注明了“不可撤销”字样，且规定了要约的有效期，但要约人随即发出撤回通知，且撤回通知早于要约到达，要约被撤回，合同不成立。

【例 2-4】分析

本题考核的是要约的撤回与撤销，以及合同的效力问题。根据题意：①可以采用要约撤回的方式，只要撤回通知早于要约到达，要约即可被撤回；②可以采用要约撤销的方式，在要约到达之后，受要约人接受之前，在符合要约撤销法定要件的情况下，要约人可依法将要约撤销；③在受要约人依法作出有效承诺的情况下，合同已经成立，此时要约人（合同一方）在未取得对方同意的情况下不得随意变更合同。若能协商变更合同当然好，但根据本案情形，可考虑依据重大误解（或国际商法基于 mistake 订立的合同）原则可申请变更或撤销合同，从而尽可能挽回损失。

【例 2-5】分析

本题考核的是要约的终止或失效问题。根据题意可知，受要约人已经对该要约予以拒绝，此时要约已经终止。之后受要约人的所谓接受，只能看作是一个新要约，合同是否成立，要看甲公司的意思表示。但如果乙公司用挂号信表示拒绝，又改变主意，用更快的方式表示接受，且接受早于拒绝到达，则合同成立。

【例 2-6】分析

本题考核的是要约的终止或失效问题。英商 6 月 2 日的接受因为提出必须要降价 5%，对价格进行了讨价还价，实际上构成反要约，原要约已经被终止，此后英商提出的接受原要约，只能看作是一个新要约。中方公司实际上就处于一个典型的受要约人的地位，可以沉默、可以拒绝、可以接受、可以还价，实际上具备了一个受要约人所具有的所有的权利。

【例 2-9】分析

本题考核的是对要约的实质性变更与变更请求的区别。我们知道，要约的内容要具体确定，前面香港公司的几次询问，都不属于对要约的实质性变更，最后表示接受，合同成立。

【例 2-10】分析

本题考核的是对要约的实质性变更，甲公司对价格的讨价还价视为反要约，要约已经被终止，8 月 29 日的所谓接受，只能视为新要约，合同因此未成立。

【例 2-13】分析

本题考核的是缔约过失责任，结合题意，综合考虑，我们发现第三种意见是最合理的，被告的行为已经足以使原告相信其捐款的真实性，基于这项信赖，原告按照被告的要求作了一系列准备工作，结果造成了原告的损失，被告需要承担缔约过失责任，赔偿原告的损失。

【例 2-14】分析

《民法典》第一百五十九条规定，附条件的民事法律行为，当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就；不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。本案甲为了自己的利益，不正当地阻止条件成就，应视为条件已成就，甲需返还借款给乙，并承担赖账期间的利息。

【例 2-16】分析

公平原则是指在民事活动中以利益均衡作为价值判断标准，在民事主体之间发生利益关系摩擦时，以权利和义务是否均衡来平衡双方的利益。本题中，乙、丙等购房人虽然与甲公司签订了《退款协议书》，但是并非出于自愿，而是在无奈的情况下签订的。在该《协议书》中，乙、丙等购房人被迫放弃了数额巨大的利息、违约金支付的要求，该约定显然是显失公平的。《民法典》第一百五十一条规定，一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使民事法律行为成立时显失公平的，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。因此，为保护购房人的利益，法院应当依据购房人的要求撤销该协议，由甲公司支付利息和违约金，因此答案为 C。

【例 2-17】分析

本案非常典型，作为剖析善意取得制度很具有代表性。一审法院驳回乙的诉讼请求并没有错，虽然甲、丙串通起来，丙并非善意受让人，但根据“谁主张谁举证”的原则，乙没有证据证明丙不是善意受让人，故法院认定丙可依善意取得制度而取得房屋所有权。在这里，法院认定的是法律事实，与客观事实截然相反。而二审法院进行了改判也是对的，因为乙提供了新证据，足以证明甲丙串通起来，丙不是善意受让人的事实，这也是法律事实，与客观事实趋于一致。

【例 2-18】分析

1.张三是限制行为能力人，该合同首先界定为效力待定合同，但由于未获追认，最终应为无效合同。

2.张三如果是 19 岁，就属于完全民事行为能力人，但属于无处分权人处分他人财产，根据题意，不符合善意取得的基本条件，原所有权人有权追回（补充一点，假设此题将情节设定为善意取得成立，则根据《民法典》第三百一十一条第二款的规定，受让人依据善意取得规定取得不动产或者动产的所有权的，则原所有权人有权向无处分权人请求损害赔偿，也就是说此时原主人就有权向张三请求赔偿了）。

4. 本案原告起诉的对象是李四，由于限制行为能力人张三与李四的买卖合同最终属于无效合同，故李四应承担返还随身听的责任，若无法返还原物，则应承担金钱赔偿的责任，赔偿数额以市场价为基础考虑折旧的合理价为妥。当然，若本案随身听的主人直接起诉张三，张三亦需承担返还之责，若无法返还原物，张三亦应承担金钱赔偿之责。

【例 2-19】分析

1.本案中，杭州公司可以行使不安抗辩权，暂停发货；

2.若杭州公司在消息不确切的情况下擅自停止发货，则要承担违约责任；

3.若日本公司以其在杭州的分公司的一批机器设备作为抵押担保，如担保是充分的，杭州公司就应该恢复履行；

5. 若日本公司确实被宣告破产，且也未能提供任何担保，杭州公司则可以解除合同并追究对方的违约责任。

【例 2-21】分析

1.对于本案的第一个问题，法院认为，被告王成钢作为该笔借款的担保人，在借条上未明确约定保证方式，根据《民法典》第六百八十六条第二款的规定，当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。关于被告担保到还款期即作废的主张，根据《民法典》第六百九十二条的规定，约定的保证期间早于主债务履行期限或者与主债务履行期限同时届满的，视为没有约定；没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起六个月。故对此主张不予采信，应按照自主债务履行期届满之日起六个月内计算保证期间。故判决被告偿还原告借款本息。

2. 对于本案第二个问题，虽然王成钢在电话中表示同意继续提供担保，但由于主合同已变更，保证合同的变更也需要书面形式，本案王成钢只是在电话中表示同意，并没有采用书面形式，王成钢无须承担担保责任。

【例 2-23】分析

1.借贷法律关系、保证法律关系、抵押法律关系；

2.保证人在担保人一栏签名，但没有注明一般保证还是连带保证的，在《民法典》2021 年 1 月 1 日实施之前，视为连带责任保证；在《民法典》实施之后则视为一般保证；

3.赵男可以与抵押人协商以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿，相对而言，折价的方式最为简便；

3. 第一笔借款可以要求李女承担保证责任，第二笔借款有抵押物，可以与抵押人协商以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿。

【例 2-24】分析

根据法律规定，抵押权与质权均是依当事人合意而成立的，但留置权则是法定的担保物权，因此在上述三种权利并存时以留置权人优先受偿。剩下的抵押权与质权，如果抵押权经法定登记，登记的抵押权优先于未登记的抵押权。根据《民法典》第四百一十五条的规定，同一财产既设立抵押权又设立质权的，拍卖、变卖该财产所得的价款按照登记、交付的时间先后确定清偿顺序。

故本案例中，该批机器设备应按顺序优先清偿 E 的修理费用、B 的债权、C 银行的欠款，最后是 D 的债权。但需要注意的是，质权人有妥善保管质押财产的义务，因此修理费用应由 B 承担，在偿还 B 的债权时应予以扣除。

需注意三点：第一，从《民法典》的规定来看，抵押权人是否善意则不在考察之列；第二，未登记的抵押权在司法实践中不具有优先权，等同于一般债权；第三，未登记的抵押权不分先后，按债权比例清偿。

【例 2-25】分析

根据《民法典》第四百一十四条至四百一十六条的规定，结合例 2-24 的分析内容，本题的清偿顺序应该是留置权最优先，其次是已经登记的抵押权，再次是质押权（注意：这里质押权位列已登记的抵押权之后，是因为抵押登记的时间早于质权设立的时间），最后是未登记的抵押权，故清偿顺序是丁、乙、丙、甲。

【例 2-28】分析

本案不仅探讨了定金与违约金的并用问题，还涉及定金支付的规则，即：在一方当事人仅仅是迟延履行而没有不履行合同的情况下，采用定金罚是不合适的，因为，作为一种债的担保形式，定金罚是在债不履行时采用的责任形式。因此，即使本案发生在合同法还没有颁布、定金和违约金的并用并未禁止的 1997 年，定金罚也不应该采用。至于违约金，合同已经规定为不能履约部分的 5%，故对于按期交货的那 500 台货物，无需承担相应的违约责任。假如卖方一直没有交付剩余的 500 台，此时可以以合同规定的一半的金额适用定金罚。

【例 2-29】分析

此案争议的焦点在于不可抗力的认定上。辽粤公司遭遇水灾的事实，符合辽粤公司以不可抗力抗辩本案被告的法定理由，但被告不能以辽粤公司发生水灾的事实作为抗辩原告的理由，毕竟，中国有对虾的公司不是只有辽粤公司一家，作为本案卖方的被告，在发现辽粤公司遭遇水灾的事实后，应该尽力通过其他渠道去其他产地组织货源，而不能借口其货源渠道之一的辽粤公司遭遇水灾的事实来抬价及不履行合同。退一步说，即使被告遭遇了不可抗力，根据《民法典》第五百九十条的规定，也应该履行通知义务，本案被告亦未履行这一义务。

【例 2-30】分析

此案考核的内容涉及《民法典》第五百六十三条以及第五百九十条的内容。本案中，甲公司没有按照合同规定的时间交付标的物，当然构成违约，而且根据《民法典》第五百九十条的规定，当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任，本案甲公司迟延履行后发生了不可抗力，因此不能免除责任。此外，根据《民法典》第五百六十三条的规定，当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，另一方有权单方解除合同。

【例 2-31】分析

本案中，我们可以认定违约方棉花供应商应当能预见到受损方棉花加工厂主张可得利益损失。这是因为：受损方在合同上盖的是棉花加工厂的章，作为违约方棉花供应商，他在缔约时知道受损方的身份，应当能预见到，他如果违约不把棉花卖给棉花加工厂，棉花加工厂肯定要受到生产利润的损失。但是，如果棉花加工厂购买的棉花并不是用来加工，而是用来转卖以挣取差价，这时他就不能把转售利润损失作为可得利益损失而要求棉花供应商赔偿，因为棉花供应商在缔约时只知道对方是一个棉花加工企业而不是商贸企业，不可能预见到棉花加工企业是把棉花进行转售。因此，在适用可预见规则时，应当依据合理标准（包括身份标准）认定违约方应当预见到可得利益损失的类型和数额，如果受损方是生产企业，那么违约方应当预见到的可得利益损失就是生产利润损失，而不是转售利润损失。

【例 2-32】分析

《民法典》第五百九十一条“减损规则”在本案中得以很好体现。本案原告在被告出现未及时提货的违约情形时，没有采取适当措施致使损失扩大，根据《民法典》第五百九十一条的规定，不得就扩大的损失要求赔偿。

【例 4-1】分析

《公司法》第十六条第一款规定，公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议；公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的，不得超过规定的限额。《公司法》第十六条第二款又规定，公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东，不得参加前款规定事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。

第一个案例中，a 同意为 B 提供担保，只是其个人同意，并没有由董事会或股东会作出决议，第二种情况的表决，则违反了公司法的程序性规定。这种担保的责任如何？

从司法实践中的法院判决来看，很多法院包括最高法院都认为，《公司法》第十六条第二款的规定是管理性强制规范，而非效力性规范，主要适用于调整公司内部法律关系，不能对抗债权人等公司以外的善意第三人。故 A 公司还是应该承担担保责任。我觉得这个问题值得探讨。在实践中，公司的法定代表人绕开董事会或者股东会、股东大会，擅自以公司的名义对外提供担保的现象十分普遍。面对法定代表人甩来的这口“黑锅”，公司是否必须得背？这是司法实践中长期以来争论不休的一个热点问题。目前理论界和实务界的主流观点是：《公司法》第十六条应理解为对法定代表人权限的法定限制，违反该条规定签订的担保合同的效力的判定应以相对人是否知道或应当知道法定代表人超越代表权限为认定基础。

那么，这又引起了第二个争论：相对人是否负有审查义务？

有观点认为，相对人负有实质审查义务。另一种观点则认为，相对人仅负有形式审查义务，而对于文件的真实性、合法性、有效性等实质性问题则无须进行审查。我个人同意第二种观点。因为相对人作为公司之外的第三人，很多时候根本没法实质审查，如果硬性要求，容易滋生公司随意的以相对人未尽到审查义务为由否定担保合同效力的道德风险。主流观点也认为相对人仅负有形式审查义务，包括最高院在（2007）民二终字第 184 号判决中就认为，“只要审查董事会决议的形式要件是否符合法律规定，银行即尽到了合理的注意义务。”“决议上的签名是否为董事亲笔所签，则属于实质性审查的范畴，银行对此并无法定义务”。可见，相对人仅负形式审查义务相对是合理的，也获得司法实践的认可。

【例 4-2】分析

本题主要考核《公司法》第二十条的规定，根据该条规定，公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

【例 7-3】分析

“风帆”牌蓄电池是国产名牌机动车蓄电池，“红牛”是驰名商标，后几个除了“H”符合规定外，都是典型的“直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点”。

【例 7-6】分析

这种情况就是属于典型的交叉型强制许可。根据《专利法》的规定，一项取得专利权的发明或者实用新型比以前已经取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进

步，其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施的，国务院专利行政部门根据后一专利权人的申请，可以给予实施前一发明或者实用新型的强制许可。同时，也可根据前一专利人的申请，给予实施后一项专利的强制许可。

【例 10-1】分析

不可以，因为志愿者是无偿性质的劳动，即使可能拿到一天十几块钱的补贴，但是就其性质而言并非劳动者，不是劳动法调整的对象。

【例 10-2】分析

劳动合同未约定期限并不意味着没有终止时间，无固定期限合同并非等于不得解除的合同，不是“铁饭碗”，一旦出现了法定情形或者双方协商一致解除的，无固定期限劳动合同同样能够解除。

【例 10-7】分析

在劳动合同中，违约金的作用是什么？简单的说，就是用人单位绑住劳动者的“紧箍咒”。但是，用人单位并不能轻易绑住劳动者，劳动合同中约定违约金，只有两种情况下才可以有效“绑住”劳动者：第一是基于培训服务期而约定的违约金（《劳动合同法》第二十二条）；第二是竞业限制违约金（《劳动合同法》第二十三条）。本案约定的违约金显然不符合劳动合同法的规定，劳动者无须支付该违约金。

【例 10-9】分析

集体合同的目的是确定一个整体上的劳动标准，而非确定具体的劳动关系，不能用以替代劳动合同。用人单位未与劳动者签订劳动合同时，用人单位不能以已经与劳动者签订集体合同为由拒绝支付（双倍工资）。

【例 10-17】分析

在本案中，若甲可以证明乙公司保证 2010 年 7 月还钱，则用人单位承诺支付之日为劳动争议发生之日，即 2010 年 7 月才是劳动争议发生之日，那么当然未超过时效；但是甲若没有证据证明乙公司承诺，则解除劳动关系之日即为劳动争议发生之日，此时时效当然已经过了。